

VALIDEZ, EFICACIA Y LA NORMA HIPOTÉTICA FUNDAMENTAL EN EL PENSAMIENTO DE HANS KELSEN

Por Benjamín García Holgado

RESUMEN

En este ensayo analizo la ambigua relación entre los principios de validez y eficacia y el concepto de Norma Hipotética Fundamental. Examino esta tensión conceptual para comprender de qué forma Kelsen responde a estas preguntas: "What constitutes the unity of a multitude of norms?; Why does a certain norm belong to a certain order?; Why is a norm valid?; What is the reason for its validity?" (Kelsen, 1960, 193). Para comprender la génesis y estructura de la Norma Hipotética Fundamental y para entender la lógica que subyace a esta tensión estructural entre la validez y la eficacia, analizo la diferencia entre el sentido objetivo y subjetivo de las normas. Asimismo, explico el criterio que le permite a Kelsen diferenciar una banda de ladrones de un Estado. Por último, examino el concepto de revolución y de cambio de un sistema jurídico para aclarar la tensión estructural entre los conceptos de validez y eficacia.

PALABRAS CLAVE

Norma Fundamental; Eficacia; Validez; Teoría Pura Del Derecho; Hans Kelsen

VALIDITY, EFFECTIVENESS AND THE BASIC NORM IN THE THOUGHT OF HANS KELSEN

By Benjamín García Holgado

ABSTRACT

In this essay I discuss the unclear relationship between the principles of validity and effectiveness and the concept of Basic Norm. I examine this conceptual tension to understand the way Kelsen deals with these questions: "What Constitutes the unity of a multitude of norms?; Why does a certain norm belong to a certain order?; Why is a valid norm?; What is the reason for its validity? "(Kelsen, 1960, 193). In order to comprehend the genesis and structure of the Basic Norm and to understand the logic behind this structural tension between validity and effectiveness, I discuss the differentiation between the subjective and objective meaning of a norm. Furthermore, I explain the criterion that allows Kelsen to differentiate a gang of robbers from a State. Finally, I examine the concept of revolution and change of a legal system to enlighten the structural tension between the concepts of validity and effectiveness.

KEYWORDS

Basic Norm; Effectiveness; Validity; Pure Theory Of Law; Hans Kelsen

VALIDEZ, EFICACIA Y LA NORMA HIPOTÉTICA FUNDAMENTAL EN EL PENSAMIENTO DE HANS Kelsen¹

Por Benjamín García Holgado*

1. Conceptos fundamentales de la Teoría Pura

Según Kelsen, sólo se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas válido. El jurista se refiere a distintos conceptos de validez de las normas y de los sistemas jurídicos. En primer lugar, que una norma sea válida significa que existe y pertenece a un sistema jurídico particular. En segundo lugar, la validez de las normas depende de un criterio formal (no material) de tipo procedimental. Es decir, la norma B es válida si y solo si el órgano gubernamental competente y autorizado por la norma A, que tiene una jerarquía superior a la norma B, siguió el procedimiento adecuado y estipulado (en la norma A) cuando creó a la norma B. En tercer lugar, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este sistema les imponen. Sin embargo, esta igualación de validez y obligatoriedad (no moral) del derecho tiene un significado especial y original (Nino, 1998, 256). Las personas tienen la obligación, el deber, de comportarse en la forma en que las normas lo prescriben. Las normas, dice Kelsen, tienen fuerza vinculante, obligan, imponen un deber, no en sentido moral, sino en sentido jurídico-objetivo. Este trabajo busca reflexionar sobre este “deber jurídico-objetivo”.

Mi interpretación, en este punto, es contraria a la expuesta por Alf Ross, que acusa a Kelsen de ser un quasi-positivista. Ross interpreta que Kelsen sostiene que si un sistema de normas jurídicas es válido, entonces es legal y posee una fuerza *moral* y jurídica absolutamente obligatoria (Ross 1998: 159-169). Según la exégesis de Ross, Kelsen representa una doctrina ideológica, que se desprende del derecho natural, denominada “quasi-positivista” (“natural law philosophy of the quasi-positivist kind”): se debe obedecer al derecho positivo por la sola razón de que es válido. En este sentido, Carlos Nino afirma que Ross sostiene que el jurista vienés es un representante del “positivismo ideológico”. Sin embargo, según mi visión, Kelsen deja muy en claro la diferencia entre un *ought* moral y absoluto y un *ought* jurídico y relativo.

Explicar en qué consiste la diferenciación que Kelsen desarrolla entre el sentido subjetivo y objetivo de las normas jurídicas y las órdenes no jurídicas es central para comprender el concepto de Norma Hipotética Fundamental. Según Kelsen, un *ought* es el sentido subjetivo de cualquier acto de la voluntad de A dirigido al comportamiento de B. Si A le dice a B: “Si no me entrega 1000 \$, lo voy a encerrar y se los voy a quitar por la fuerza”, está enunciando una orden cuyo sentido subjetivo es un *ought* que un sujeto le impone a otro. En esta situación, B está obligado solamente en sentido subjetivo a cumplir la orden de A. Por eso, Kelsen aclara que no todos los actos de voluntad de un sujeto tienen también un sentido objetivo. Si el contenido de un acto de voluntad (que es un *ought*) tiene también un sentido objetivo, se está enunciando una norma, no una orden. Entonces, una

¹ Utilizaré las últimas ediciones que fueron traducidas al inglés de las principales obras de Kelsen: *Pure Theory of Law* y *General Theory of Law and State*. Por cuestiones de hermenéutica decidí no traducir las citas ni los conceptos para no alterar su significado.

* Estudiante de Ciencias Políticas, Universidad de San Andrés.

norma válida y obligatoria siempre establece un *ought* obligatorio en un sentido objetivo. Kelsen define el sentido objetivo de un acto como: “the behavior at which the act is directed is regarded as something that ought to be not only from the point of view of the individual who has preformed the act, but also from the point of view of the individual at whose behavior the act is directed, and of a third individual not involved in the relation between the two” (Kelsen, 1960, 7-8). Es decir, el sentido objetivo de una norma es, de alguna forma, independiente del acto de voluntad inicial que dio origen a la norma. Por otro lado, un sujeto debe comportarse como lo indica el sentido objetivo de una norma aunque desconozca la existencia del acto de voluntad originario que creó esta norma. Kelsen aclara, por último, que la existencia misma del sentido objetivo de una norma depende directamente de que el acto de voluntad que crea la norma fuera autorizado por una norma superior para hacerlo.

Entonces, se puede establecer una diferencia fundamental entre el pedido de dinero que realiza un ladrón y el de un recaudador de impuestos. La exigencia, el *ought* creado por el acto de voluntad de ambos, tiene el mismo sentido subjetivo: “the individual at whom the command is directed ought to pay something” (Kelsen, 1960, 8). Sin embargo, la ordenanza, el *ought* que es creado por el acto de voluntad del recaudador de impuestos es una norma válida vinculante (*binding valid norm*), ya que este acto de voluntad está autorizado por una norma superior (norma impositiva) para crear esta norma válida vinculante. A su vez, el acto de voluntad de los legisladores, cuando crearon esta ley tributaria, tiene un sentido objetivo, ya que la Constitución, que es la norma positiva superior del sistema jurídico, los ha autorizado para que todos los actos de voluntad que fueron realizados de cierta forma, sean válidos y obligatorios. Sin embargo, el problema fundamental se encuentra en el concepto mismo de la Constitución que sea obligatoria, que imponga un *ought* objetivo. Siguiendo el razonamiento de Kelsen, si afirmamos que la Constitución es una norma con un *ought* con un sentido objetivo y obligatorio, que le otorga validez a todas las normas inferiores, debe existir una norma anterior a la Constitución que le otorgue su validez y obligatoriedad. Esta norma, que le otorga validez a todo el sistema jurídico y que permite realizar el primer “juicio de validez” de toda la “cadena de validez” de un sistema jurídico (Nino 1998, 257-258), no es positiva sino presupuesta, y es llamada Norma Hipotética Fundamental (Kelsen, 1960, 8-9).

Entonces, la razón o causa lógico-formal que posibilita que una norma sea válida, es decir, que obligue, no se puede encontrar en un hecho: “The objective validity of a norm, which is the subjective meaning of an act of will that men ought to behave in a certain way, does not follow from the factual act (from an *is*), but again from a norm authorizing this act (from an *ought*)” (Kelsen, 1960, 193).

Por lo tanto, solo se puede afirmar que el recaudador de impuestos, a diferencia de un ladrón, no emite órdenes, sino normas, que poseen un *ought* con sentido objetivo y vinculante, si y solo si el agente estatal se encuentra autorizado, por una norma jerárquicamente superior y válida, a emitir, de una forma determinada, cierto tipo de normas. Es decir, lo que diferencia a uno del otro, es la existencia o ausencia de una “cadena de validez”, que permita derivar un *ought* de otro *ought* y no de un *is*. Pero, si en vez de un ladrón, hubiera un grupo de ellos, organizados jerárquicamente, que ocupan un territorio y cuyos mandatos son obedecidos por la población, en este caso, ¿sus mandatos, sus *ought*, serían objetivamente obligatorios y válidos? En últimas, siguiendo la hermenéutica que propone Kelsen, ¿por medio de qué criterios se puede diferenciar una banda de guerrilleros de un Estado republicano? Después volveré sobre esta pregunta.

Es importante recordar que Kelsen se propone crear una Teoría Pura del Derecho que tiene como uno de sus pilares atacar la falacia que David Hume le imputa a las doctrinas del derecho natural (“from the circumstance

that something is cannot follow that something *ought to be*"). Comprender esta crítica, característica del positivismo jurídico, es central para la interpretación de toda la obra de Kelsen, que se aboca a crear una teoría del derecho positivista. Las escuelas del Derecho Natural son diversas, pero todas afirman la existencia de principios morales trascendentes, metafísicos y vinculantes, no creados por el hombre, sino descubiertos por él. Estos principios son obligatorios para todos los hombres, constituyen los máximos criterios evaluativos que le otorgan validez al derecho positivo. Es decir, si el derecho positivo no es una copia justa del derecho natural, carece de validez, y por lo tanto, de obligatoriedad. Hume critica a estas doctrinas que sostienen que existe un orden natural que tiene mayor densidad metafísica y moral, que posee mayor existencia y que es, en definitiva, más real. En este sentido, Kelsen quiere, como señalé, una teoría del derecho en la cual el ser no se convierta en deber ser. Por lo tanto, el origen de la validez de una norma, para no caer en la falacia naturalista, sólo se la puede encontrar en la validez de una norma superior que se la otorgue. De esta forma, se estaría derivando un *ought* no a partir de un *is*, sino de un *ought* superior, que le otorga validez a una norma inferior. En este sentido, Kelsen siempre afirma que el derecho regula su propia creación, y que su validez y legitimidad no depende de consideraciones políticas, sociales o morales.

Veamos todo lo expuesto en un caso concreto. La razón para obedecer la Ley 20.628 (impuesto a las ganancias) que emite el Congreso (*is-statement*) no se encuentra en el hecho de que el parlamento emitió esta ley (*is-statement*), sino la presunción de una norma tácita y presupuesta que sostiene que todos debemos cumplir con todas las leyes que emite el Congreso (*ought-statement*). Kelsen presenta un silogismo compuesto por tres premisas.

La premisa mayor es un *ought-statement* (debemos obedecer las leyes que provienen del parlamento). Es una norma presupuesta y tácita. De esta se deriva lógicamente una nueva premisa mayor, un nuevo *ought-statement*, que declara la validez de todas las leyes tributarias que sanciona el parlamento (debemos obedecer las leyes tributarias que emite el parlamento). La conexión esencial es la premisa menor, que postula un *is-statement*, un hecho (el congreso emitió la Ley 20.628). Siguiendo el razonamiento, la conclusión del silogismo es un *ought-statement* (debemos obedecer la Ley tributaria 20.628). Entonces, la premisa mayor y la conclusión siempre son un *ought-statement*, mientras que la premisa menor es un *is-statement*. La norma cuya validez se afirma en la premisa mayor es la *conditio per quam* de la validez de la norma cuya validez se sostiene en la conclusión. La validez de la conclusión se deriva de la validez de la premisa mayor. La premisa menor, que es un *is-statement*, funciona como la *conditio sine qua non* en relación a la validez de la conclusión: "the fact whose existence is asserted in the minor premise is not the reason for the validity of the norm whose validity is asserted in the conclusion" (Kelsen, 1960, 194).

La Norma Hipotética Fundamental (a partir de ahora, NHF) es la premisa mayor del sistema jurídico. Entonces, su validez no se deriva de una norma superior sino que se presupone. En este sentido, para Kelsen, la razón de su validez es incuestionable. Como es la norma más alta (supuesta) no hay una norma superior con la que se pueda verificar su validez. No es una norma positiva, es decir, puesta por una autoridad cuya competencia válida descansa en una norma superior.

Kelsen responde a las cuatro preguntas formuladas al inicio mediante su concepto de NHF. Todas las normas cuya validez se derivan de una única NHF constituyen un sistema de normas u orden normativo. Por lo tanto, la NHF es la fuente común que le da validez a todas las normas que pertenecen al mismo orden jurídico, constituye la fuente misma de unidad de la multiplicidad de normas de un sistema jurídico.

La característica formal y *no material* (no tiene un contenido moral o político) de la NHF permite que el derecho, a diferencia de otros sistemas de normas como los que pertenecen al Derecho Natural, sea un sistema *dinámico* de normas. La NHF sólo contiene la determinación de un "norm-creating fact" (Kelsen, 1960, 196): "The

basic norm merely establishes a certain authority, which may well in turn vest norm-creating power in some other authorities [...] is the fundamental rule according to which the norms of the system are to be created" (Kelsen, 1945, 113). En definitiva, la NHF es una regla formal que establece de qué manera las normas generales e individuales de un orden legal (que fundamentan su validez en esta misma NHF) deben ser creadas. Las normas forman parte de un sistema jurídico si han sido creadas en una forma determinada y autorizada por la NHF. Entonces, las normas son válidas sólo si cumplen con el procedimiento que ha sido establecido en la NHF, sin importar su contenido. Es la adecuación al proceso específico de creación de normas respecto de la NHF lo que otorga validez a las normas particulares y generales.

2. Presentación del problema

El problema central de la Teoría Pura es determinar cuándo debemos presuponer la existencia de una Norma Hipotética Fundamental que le otorgue validez a un sistema jurídico. Es decir, es el antiguo problema que está presente en la filosofía política y del derecho que consiste en establecer algún tipo de criterio que permita diferenciar a un Estado de un grupo de ladrones. Asimismo, también consiste en la dificultad de determinar si una revolución, que tiene por objetivo el cambio de un sistema jurídico por otro, es exitosa o no. En estas dos situaciones se evidencia la tensa relación entre los principios de la validez y la eficacia y la Norma Hipotética Fundamental. Kelsen intenta resolver esta tensión sin caer en la falacia del Derecho Natural, pero incurre en varios argumentos contradictorios y poco claros.

Por una lado, Kelsen afirma que "the basic norm is presupposed when the custom through which the constitution has come into existence, or the constitution-creating act consciously performed by certain human being, is objectively interpreted as a norm creating fact, if, in the latter case, the individual or the assembly who created the constitution on which de legal order rest, are looked upon as norm-creating authorities" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1960, 199). Luego vuelve a definir la NHF como "a norm presupposed if the subjective meaning of the constitution-creating facts and the subjective meaning of the norm-creating facts established according to the constitution are interpreted as their objective meaning" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1960, 200). Es decir, la NHF debe ser presupuesta después de observar empíricamente que los individuos previamente reconocen e interpretan a las órdenes subjetivas que les son impuestas por las normas como objetivamente válidas, es decir, como normas que provienen de un poder válidamente autorizado. La existencia misma de esta NHF depende de que el observador del derecho suponga que ocurre previamente este reconocimiento por parte de las personas. Por eso, la NHF no puede garantizar en ningún caso la eficacia del sistema jurídico (Kelsen 1965: 1140-1141). En cambio, su existencia misma depende de que un sistema jurídico sea eficaz.

Mi interpretación es que Kelsen supone que si un sistema de normas es eficaz, esto implica que las personas previamente realizan un proceso de interpretación por medio del cual reconocen las normas de un sistema (y al sistema como un todo) como objetivamente válido. Por esto, solamente los sistemas legales coercitivos que son efectivos poseen una NHF. Por lo tanto, la NHF se "adapta" a este orden coercitivo eficaz, ya que el jurista, desde el punto de vista de la ciencia del derecho, debe presuponer una NHF solamente cuando analiza un orden social coercitivo efectivo (Kelsen 1965: 1142). Sólo podemos postular la existencia de una NHF que le otorga validez a un sistema solamente si éste es, previamente, eficaz.

Por lo tanto, para Kelsen, la validez de la NHF del sistema X está estrechamente vinculada a la eficacia previa de este sistema X. La validez del sistema depende de su nivel de eficacia, no de una NHF que lo trasciende y

es anterior a él. La NHF solamente puede ser presupuesta como válida y constituirse como fuente de validez de todo el sistema jurídico en aquellos casos donde observamos empíricamente un sistema jurídico eficaz: "Effectiveness is stipulated as a condition for the validity [of the legal system as a whole] by the basic norm" (Kelsen, 1960, 208). Kelsen busca establecer la validez del sistema en la eficacia del sistema mismo. De alguna forma, el sistema es válido, tiene normatividad, es obligatorio, como consecuencia de su eficacia. La NHF sólo existe en sistemas legales eficaces, donde la validez objetiva de este sistema no depende, en últimas, de la validez presupuesta de esta NHF, sino de un proceso de reconocimiento de los que aplican y obedecen el derecho. En definitiva, es este proceso de reconocimiento que realiza la población lo que le da eficacia y, por lo tanto, validez al sistema.

En conclusión, solo se podría presuponer la existencia de la NHF (*ought-statement*) luego de verificar el establecimiento de normas por actos de voluntad (*is-statement*) y que estas normas sean: 1. Interpretadas y reconocidas por la población como si fueran objetivamente válidas. 2. Efectivamente cumplidas y aplicadas (*is-statement*) por los individuos.

Sin embargo, Kelsen también afirma que "the function of the basic norm is to make it possible to consider the *subjective meaning* of the law-creating acts -which is an *ought*- as their *objective meaning*, and thus as objectively norms [y no solo como órdenes con un *ought* con sentido solamente subjetivo]. Only if we presuppose the basic norm can we consider a coercive order which is by and large effective as a system of objectively valid norms. Consequently, the foundation of the objective validity of the legal norms is conditional, conditioned by the presupposition of the basic norm" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1965, 1145). Kelsen, a diferencia de lo que afirmó en el apartado anterior, asegura que la *presuposición* de la NHF le otorga validez al sistema jurídico y que permite considerar las órdenes subjetivas que establecen las normas como objetivamente válidas.

No queda claro, por lo visto anteriormente, si la NHF otorga validez a un sistema jurídico eficaz, o si por el contrario, todo sistema jurídico eficaz (en el cual las personas, al obedecer las normas reconocen a los *oughts* como objetivamente válidos) permite suponer una NHF que, a su vez, "establezca" la validez del sistema. Según mi interpretación, la validez ya habría sido establecida previamente cuando las personas realizan un juicio de validez donde reconocen los *oughts* que les imponen el contenido de las normas como objetivamente válidos.

En el primer caso, se subordina la eficacia a la validez. En el segundo, la validez se subordina y depende de la eficacia del sistema. En este sentido, Kelsen debería aclarar que la presuposición, desde la ciencia del derecho, de la existencia de una NHF particular (fuente última y única de validez de un sistema legal), que se corresponde con un sistema jurídico específico, puede realizarse solamente después de comprobar, a través de una observación empírica que este sistema jurídico, como un todo completo y cerrado, es eficaz (o de suponer que el sistema es eficaz). Sólo el jurista puede presuponer la existencia de una NHF que le da validez al sistema jurídico X como una consecuencia de que el sistema jurídico X es eficaz. Entonces, las normas del sistema jurídico X son válidas como consecuencia de que son eficaces.

De esta forma, la NHF nunca puede entrar en contradicción con el sistema jurídico eficaz, cuya validez depende de ella (Kelsen, 1960, 217). Kelsen continúa argumentando circularmente. La NHF es la condición para la interpretación objetiva de la ley y establece la validez de cualquier orden legal positivo, que haya sido creado por la voluntad de ciertos individuos y que sea eficaz. Por lo tanto, no puede existir ningún sistema jurídico eficaz que no se corresponda con su NHF: "It is imposible that a positive legal order is not in conformity with its basic norm and hence not valid" (Kelsen 1959: 109). Todo sistema jurídico eficaz es válido, y por lo tanto, posee una Norma Hipotética Fundamental, que le otorga validez.

A partir de estas afirmaciones, se puede extraer la siguiente conclusión: la validez (es decir, la existencia lógico-explicativa) de la NHF (que permite considerar a todo el sistema como válido) es un efecto, una consecuencia, de la eficacia real del sistema jurídico. Sin embargo, la validez de un sistema de normas (que los *oughts* de las normas sean reconocidos como objetivos y no meramente subjetivos, es decir, que sean obligatorios) depende, a su vez, de que se presuma la existencia de una NHF. Pero, la NHF sólo es válida y puede ser presupuesta si se refiere a un sistema jurídico eficaz. El problema con este razonamiento es su circularidad. Además, Kelsen estaría afirmando un *deber* (*ought-statement*) que se encuentra expresado en la NHF, premisa mayor incuestionable (*one ought to behave as the constitution prescribes*), como consecuencia necesaria de la existencia de un *hecho fáctico* (*is-statement*), que consiste en una observación empírica (la gente obedece al derecho en un sistema jurídico).

3. Situaciones problemáticas: banda de ladrones y revolución

La paradoja mencionada anteriormente se evidencia claramente en dos situaciones especiales. La primera consiste determinar cómo podemos diferenciar a los mandatos de una organización delictiva de los mandatos normativos del sistema legal (Kelsen, 1960, 44-50). La segunda consiste en una revolución que cambia la Norma Hipotética Fundamental. El análisis de estos dos momentos es esencial para el objetivo de este trabajo: establecer los verdaderos criterios que diferencian una norma (con un *ought* con sentido objetivo, es decir, válido y obligatorio) de una orden y determinar en qué momento el jurista debe presuponer una NHF.

3.1 ¿En qué se diferencian una banda de ladrones de un sistema jurídico?

Como señalé antes, la orden de un ladrón hacia otra persona exigiéndole su dinero, posee, en sentido subjetivo, el mismo significado que tiene la orden de un recaudador de impuestos cuando le exige el pago de una suma a esa persona. En ambos casos, se establece un *ought* que puede o no ser cumplido: "So far as only the subjective meaning of the acts are considered, there is no difference between describing the command of a robber and the command of a legal organ" (Kelsen, 1960, 44-45)

Sin embargo, la orden del recaudador tiene sentido normativo y es realmente, en un sentido jurídico, desde el punto de vista objetivo, obligatoria y vinculante. La diferencia entre ambos está dada por el sentido objetivo de la acción: "The meaning of a *threat* is that an evil will be inflicted under certain conditions, the meaning of a legal order is that certain evils ought to be inflicted [...] or that certain coercive acts *ought to be* executed under certain conditions" (Kelsen, 1960, 45). La existencia de esta diferencia entre el *will* y el *ought* es causa de la ausencia de una "cadena de validez", que permite que el *ought* de la norma jurídica sea considerado objetivamente válido y vinculante. En ese caso, el *ought* no se estaría derivando de un *is*, sino de un *ought* superior. Por lo tanto, la persona solo se encuentra realmente obligada (en sentido objetivo) hacia el recaudador de impuestos.

Se podría encontrar algún tipo de similitud entre el sentido subjetivo de una orden en Kelsen y las regularidades relacionadas con el punto de vista externo de H.L.A. Hart. Asimismo, en términos de Hart, se podría sostener que el sentido subjetivo de la orden del ladrón hace que la otra persona se vea obligada a entregar su dinero. Sin embargo, la norma que emite el recaudador de impuestos, posee un sentido objetivo, que produce que la persona tenga una obligación.

Kelsen realiza nuevamente la pregunta "Why do we interpret the subjective meaning of the one act also as its objective meaning, but not so of the other act?" (Kelsen, 1960, 45) y la responde analizando todos las etapas de la

“cadena de validez” hasta llegar a la Norma Hipotética Fundamental. El jurista vuelve a definir la NHF como una norma presupuesta “according to which the act whose meaning is to be interpreted as “constitution” is to be regarded as establishing objectively valid norms”. Luego, aclara que la NHF es presupuesta “if the act [whose meaning is to be interpreted as “constitution”] is interpreted as establishing a constitution and the acts based on the constitution are interpreted as legal acts” (Kelsen, 1960, 46). Es decir, la NHF permite interpretar la primera constitución positiva como una norma que, en un sentido objetivo, establece normas válidas y obligatorias. Sin embargo, aparece nuevamente la tensión entre validez y eficacia: “The basic norm which is the reason for the validity of the legal order, refers only to a constitution, which is the basis of an effective coercive order. Only if the actual behavior of the individual conforms, by and large, with the subjective meaning of the acts directed toward this behavior –if, in other words, the subjective meaning *is recognized* as the objective meaning- only then are the acts interpreted as legal acts” (Kelsen, 1960, 47). Entonces, la NHF es supuesta, desde el punto de vista de la ciencia del derecho, cuando se percibe un sistema de normas jerárquico, cerrado y completo, que es eficaz. Kelsen, de alguna forma, está afirmando que si el comportamiento externo de los individuos se corresponde con los *oughts* de las órdenes, si las personas cumplen con las órdenes, el sistema es eficaz, por lo tanto, válido, obligatorio y vinculante.

Es posible pensar en un sistema de normas que, como no es eficaz, sólo establece una obligación en un sentido subjetivo. Sin embargo, este sistema de normas impone una obligación, en sentido objetivo (es decir, este sistema se vuelve válido), si las personas comienzan a cumplir esos mandatos que les son impuestos. Entonces, si las personas cumplen con un sistema de normas (antes de que ellas las obedezcan, este sistema no era válido, no tiene obligatoriedad objetiva, sino sólo subjetiva) éste se “transforma” en un sistema obligatorio y válido. Las normas imponen un *ought*, en sentido objetivo, solo en la medida en que estas son eficaces.

En este punto, Kelsen entra en una contradicción interna. Si entendemos que “an objective norm is one that ought to be obeyed, subjective attitudes to the contrary or otherwise notwithstanding” (Beyleveld y Brownsword, 1998, 131), Kelsen no puede afirmar, simultáneamente, que si un conjunto de personas deja de obedecer al derecho, éste deja de ser efectivo (por tanto, deja de ser válido), perdiendo su sentido objetivo. Si afirma que como consecuencia de que un conjunto de normas dejan de ser obedecidas, éstas ya no son válidas, es decir, pierden su fuerza normativa y obligatoria, está aceptando que “from the fact that the norm is not effective it ought not to be obeyed” (Beyleveld y Brownsword, 1998, 131) y dejando un tanto olvidado su objetivo de no derivar un *ought* a partir de un *is*.

Kelsen no aclara quién decide en qué momento las órdenes deben ser interpretadas como normas válidas y vinculantes, que forman parte de un sistema jurídico. Por un lado, si las personas obedecen al sistema de normas de un orden coercitivo, éste es eficaz y, por tanto, válido, lo que le permite a un jurista, desde el punto de vista de la ciencia del derecho, afirmar que existen *ought* tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo. Por otro lado, como afirma Joseph Raz, la normatividad (es decir, interpretar los *oughts* como objetivamente válidos y vinculantes) del sistema jurídico, depende, en definitiva, de que los individuos perciban al sistema jurídico como normativo (juzgando los *oughts* que les imponen las leyes del Estado como objetivamente válidas) (Raz, 1998, 57-60).

Según mi interpretación, cuando la gente cumple con un sistema de normas, se debe dar un proceso de reconocimiento, donde las personas reconocen al derecho como un sistema de normas obligatorio, que debe ser obedecido, a diferencia de los mandatos de una organización delictiva. En algún sentido, podría ser afirmado que las personas adoptan un punto de vista interno (similar al de Hart) donde reconocen la obligación de obedecer a estas normas.

Luego, Kelsen diferencia a las órdenes de un ladrón individual respecto de las que emite una banda de ladrones: "How about a situation, however, in which an organized gang systematically jeopardizes a certain territory by forcing the people living there, under, threat, to surrender their money?" (Kelsen, 1960, 47). De acuerdo con mi interpretación, es viable definir dos situaciones posibles.

En la primera, la banda de ladrones actúa dentro de un sistema jurídico válido. Kelsen se pregunta, entonces, porqué esta banda de ladrones no es interpretada como un orden legal, es decir, porqué el sentido subjetivo de este orden coercitivo no es interpretado en sentido objetivo. Responde que esto es así ya que no se ha presupuesto una NHF "according to which one ought to behave in conformity with this order". Sin embargo, vuelve a preguntarse "why is no such basic norm presupposed? *Because this order [el sistema de normas de los ladrones] does not have the lasting effectiveness without which no basic norm is presupposed*" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1960, 47). El sistema coercitivo de los ladrones, en este caso, no tiene validez si las normas del sistema legal dentro del cual se encuentra poseen mayor eficacia, es decir, si este sistema es válido. Esta situación se da "if the coercive order regarded as the legal order is more effective than the coercive order constituting the gang" (Kelsen, 1960, 48).

Sin embargo, es posible pensar en una segunda situación, donde la validez del orden coercitivo de los ladrones (que asegura un nivel mínimo de seguridad colectiva) se restringe a una zona específica. Esta situación se puede dar aunque dicho sistema se encuentre "compartiendo" territorio con otro sistema jurídico. Además, en el territorio que se corresponde con el orden coercitivo de los ladrones, la validez de cualquier otro orden coercitivo distinto está excluida. Entonces, en este caso, el orden coercitivo del grupo de ladrones, si es eficaz, es válido y, por lo tanto, considerado como un sistema legal, un Estado (Kelsen, 1960, 48).

Kelsen explícitamente rechaza cualquier criterio axiológico que le permita diferenciar, desde el punto de vista de la ciencia del derecho, un sistema jurídico que pertenece a un Estado republicano y democrático del sistema legal de un grupo de guerrilleros, que se apoderan de un territorio, y cuyas órdenes son eficazmente obedecidas. No existe ningún tipo de diferenciación cualitativa entre un Estado y un grupo armado que aún no logra imponer sus mandatos. La diferencia entre ambos es puramente cuantitativa: solamente el nivel de eficacia de las normas de uno de los sistemas coercitivos va a determinar si éste considerado como legal o no. Es decir, un población, frente a dos órdenes coercitivos en competencia (aún ninguno es más eficaz que el otro) cuando decide comenzar a obedecer a uno de ellos por sobre el otro, está determinando que éste es un orden legal válido, es decir, un conjunto de normas que deben ser obedecidas. En algún sentido, para Kelsen, un Estado no sería mucho más que un conjunto de ladrones, delincuentes o guerrilleros organizados en un territorio determinado que logran establecer un sistema de normas jerárquico que es eficaz.

3.2. ¿Cómo determinar si existe una revolución que cambia un sistema jurídico por otro?

Para Kelsen una revolución consiste en un cambio no legítimo de una constitución válida. Es decir, un cambio cuyo procedimiento no se corresponde con el cambio de constitución que está autorizado en la misma constitución válida (Kelsen, 1945, 117 y 372). En este punto, se vuelve a notar en su razonamiento la tensión entre el principio de la validez al de la eficacia: "As the new constitution becomes valid, so simultaneously changes de basic norm" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1960, 220). A medida que los *oughts* de las normas que se derivan de la nueva constitución comienzan a ser reconocidos como objetivamente válidos, empieza a cambiar la NHF. La relación causal es clara. El nivel de eficacia del nuevo sistema legal permite la posibilidad de suponer una Norma Hipotética Fundamental, que "garantiza" la validez de la nueva Constitución y es distinta a la que existía cuando la

anterior constitución era eficaz. Queda claro que la validez de este sistema depende enteramente de la capacidad que éste tiene de ser obedecido por la población, es decir, de ser eficaz. Kelsen afirma que se produce un cambio en la presuposición que identifica el "constitution-creating fact" y los "the facts established according to the constitution" como, respectivamente, "norm-creating" y "norm-applying facts". En efecto, es el "*cambio de juicio de validez*" el que determina que una revolución sea efectiva o no. Es decir, las personas dejan de reconocer, cumplir y obedecer los *oughts* de las normas pertenecientes a un anterior sistema jurídico, que era efectivo y válido, y comienzan a reconocer, cumplir y obedecer *oughts* de normas pertenecientes a un nuevo sistema jurídico que, a medida que se vuelve efectivo, comienza a ser válido. Sin embargo, es claro que este "*cambio de juicio de validez*" no es consecuencia de un cambio previo de NHF. Por el contrario, el cambio de la NHF es una consecuencia posterior al hecho de que las personas realicen previamente este "*cambio de juicio de validez*". Es decir, que el cambio de NHF depende del nivel de eficacia del nuevo sistema. El problema fundamental se establece claramente en la siguiente afirmación: "The change of the basic norm follows the change of the facts that are interpreted as creating and applying valid legal norms. The basic norm refers only to a constitution which is actually established by legislative act or custom, and is effective. A constitution is "effective" if the norms created in conformity with it are by and large applied and obeyed. As soon as the old constitution loses its effectiveness and the new one has become effective, the acts with appear with the subjective meaning of creating or applying legal norms are no longer interpreted by presupposing the old basic norm, but by presupposing a new one" (El énfasis me pertenece. Kelsen, 1960, 210). En definitiva, el principio de validez y, por tanto, de legitimidad de un sistema jurídico depende del principio de efectividad. La NHF depende de la eficacia del sistema.

Para dilucidar, en profundidad, la manera en que Kelsen reduce la validez a la eficacia, habría que preguntarse cuál es la fuerza causal que cambia la NHF de un sistema jurídico cuando ocurre una revolución. El cambio de NHF está dado por el cambio de obediencia de los individuos, no por la fuerza coercitiva de un grupo que derroca a un gobierno constitucionalmente válido. La verdadera revolución que cambia a la NHF es una revolución en el proceso de identificación ("*cambio de juicio de validez*") y de obediencia de las normas jurídicas por parte de la población.

Imaginemos el sistema jurídico de un país en la actualidad, que es completamente eficaz y válido. Este país tuvo numerosos sistemas jurídicos, con sus correspondientes y diferentes NHF. En un momento determinado, todo el conjunto de la población comienza a aplicar, obedecer y reconocer sistemáticamente, durante un tiempo considerable, normas jurídicas pertenecientes a un sistema jurídico anterior (que solía ser eficaz y válido). En consecuencia, el actual sistema jurídico deja de ser eficaz y válido. Se estaría produciendo una verdadera revolución que cambia al sistema jurídico y a su NHF, como consecuencia de un cambio en la efectividad. La revolución, el cambio del sistema jurídico, no ocurre al nivel de la imposición, sino de la obediencia, de la eficacia.

4. Conclusiones

La tensión entre la validez y la eficacia, evidenciada en los casos de una revolución y de establecer la diferencia entre una banda de ladrones y un Estado, es un problema estructural en la Teoría Pura. Kelsen reconoce que el acto por el cual se creó la primera constitución histórica y por el cual se crean todas las normas jurídicas son un "is-fact" o "is-statement". Simultáneamente, presupone un *ought-statement* (es decir, la Norma Hipotética Fundamental) que significa la obligación de obedecer los mandatos de la actual constitución eficaz. Sin embargo, solamente puede presuponer este *ough-statement* cuando se evidencia empíricamente un *hecho social* (*the effectiveness of a*

legal system), que es un *is-statement*. Esta tensión se evidencia, una vez más, en la siguiente afirmación: "The norms of a positive legal order are valid *because* the fundamental rule regulating their creation, that is, the basic norm, is presupposed to be valid, not because they are effective, *but they are valid as long as this legal order is effective*. As soon as the constitution loses its effectiveness, as soon as the legal order as a whole based on the constitution loses its effectiveness, the legal order and every single norm lose their validity" (Kelsen, 1960, 212).

Sin embargo, Kelsen intenta resolver esta tensión al sostener que la Teoría Pura es un "middle ground" entre dos extremos (Beyleveld y Brownsword, 1989). El primero, cuyo ejemplo es una teoría idealista del derecho, sostiene que no existe conexión entre la validez (*ought-statement*) y la efectividad (*is-statement*): la validez de un sistema jurídico es completamente independiente de su eficacia. El segundo, característico de una teoría realista, establece la identidad entre la validez y la efectividad de un sistema jurídico. Asegura que su teoría no forma parte del primer extremo ya que "is undeniable that a relation exists between the *ought* of the legal norm and the *is* of physical reality also insofar as the positive legal norm, to be valid, must be created by an act which exist in reality of being" (Kelsen, 1960, 211). Por otro lado, afirma que la eficacia de un orden legal y de una norma particular es, conjuntamente con el "norm-creating act", la condición para la validez. Su estrategia, para no caer en ninguno de los dos extremos, consiste en postular dos condiciones ("the positing of the norms and the efficacy of the norms" (Kelsen, 1965, 1139) que se deben dar simultáneamente para que pueda existir la validez de un sistema legal: "The conditions of the validity of the legal order as a whole and of a single legal norm are: for the legal order as a whole, the acts by which the norms of the legal order are created, for the single norm, the act by which this norm is created, and in addition, the fact that the legal order as a whole and the single legal norm are, respectively, effective" (Kelsen, 1965, 1139). Por lo tanto, la validez, afirma Kelsen, no es idéntica a la eficacia, ya que una condición no puede ser igualada a aquello a lo que condiciona, a menos que sea la condición suficiente y necesaria.

Aunque intente evitar, mediante la inclusión de los dos elementos causales generadores de la validez, que su Teoría se encuentre en el segundo de los extremos, no lo logra. Cuando incluye a la eficacia del sistema como causa necesaria de la validez del mismo, la validez termina siendo reducida a la eficacia de las normas. En este sentido, las condiciones causales que permiten considerar a una norma como válida son dos *is-statement*.

Por lo tanto, la NHF y la validez del derecho (un *ought-statement*, que permite percibir las órdenes subjetivas de las normas como objetivamente válidas y le otorga normatividad al derecho) dependen de dos condiciones que son dos "is-statements". Aunque es cierto que Kelsen no cae en la falacia que le critica al Derecho Natural está, mediante la verificación de dos hechos (la primera constitución histórica y todas las normas del sistema jurídico son, de hecho, puestas por voluntad de las personas, que cumplen con estas normas), afirmando que las personas están objetivamente obligadas, que existe una obligación jurídica, a cumplir con los mandatos de la constitución.

Kelsen admite que el principio de efectividad limita, en parte, al de validez. La eficacia de la totalidad del sistema jurídico es una condición necesaria (*conditio sine qua non*) pero no suficiente (*conditio per quam*) para que un sistema sea válido. La eficacia del sistema es sólo una condición necesaria, no la razón suficiente para la validez de sus normas. Ella existe cuando las normas son creadas cumpliendo con los requisitos formales que les imponen las normas superiores, como consecuencia de formar parte de la "cadena de validez" (Raz, 1998, 50). Sin embargo, Kelsen es renuente a reconocer el verdadero poder causal del principio de eficacia en su sistema. En este sentido, Kelsen menciona que "a legal norm [not a legal order as a whole] becomes valid *before* it can be effective" (Kelsen 1965: 1140). Pero, considerando al sistema legal en su conjunto, ¿puede Kelsen afirmar que la validez del mismo precede a su eficacia, como sucede en el caso de la norma particular?

A Kelsen nunca le interesó responder (¿nunca pudo responder?) en sus obras a dos preguntas fundamentales. La primera es sociológica, la segunda ética. La primera de ellas consiste en poder establecer las razones por las cuales un grupo de personas, en un país y una circunstancia histórica determinada, deciden obedecer, en mayor o menor medida, al sistema jurídico. Asimismo, no ofrece una respuesta acerca de los factores que hacen que un golpe de estado determinado sea exitoso (en términos de su efectividad) para cambiar el sistema jurídico y su Norma Hipotética Fundamental. La segunda es la pregunta central de la filosofía del derecho: ¿Por qué la gente debe obedecer al derecho? Aunque la pregunta está constantemente presente (“¿Why one has to respect the first constitution as a binding norm?”). Kelsen, 1945, 116), Kelsen no la responde.

En definitiva, la crítica central del positivismo al iusnaturalismo consiste en que las obligaciones del sistema jurídico positivo no deben derivarse de un orden natural meta-jurídico. Según mi interpretación, Kelsen intenta defender la idea de que el derecho es obligatorio *qua* derecho, es decir, la obligatoriedad del sistema jurídico positivo emana, en algún punto, del propio sistema jurídico. Kelsen en ningún momento niega la existencia de lo que podríamos llamar diversas “esferas normativas” (la política, la ética, la economía) que producen distintos tipos de obligaciones y de sentidos. Sin embargo, busca señalar que la obligatoriedad que genera la “esfera normativa” del derecho no depende ontológicamente de la existencia de las otras esferas normativas. No queda demasiado claro en qué consiste una “obligación *propriamente* jurídica”. Quizás esto se deba a que Kelsen, en algún punto, siempre presupone que el derecho es obligatorio y tiene poder normativo.

BIBLIOGRAFÍA (CITADA Y CONSULTADA)

- Beyleveld, D. y Brownsword, R. (1989) “Normative Positivism: The Mirage of the Middle-Way”. En *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 9, No 4.
- Beyleveld, D. y Brownsword, R. (1998) “Methodological Syncretism in Kelsen’s Pure Theory of Law”. En *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes* (Stanley Paulson, Bonnie Paulson Ed.). Oxford University Press, Oxford.
- Hart, H.L.A. (1961) *The Concept of Law*. Oxford, Oxford University Press, 1998.
- Kelsen, H. (1945) *General Theory of Law and State*. Massachusetts, Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1960) *Pure Theory of Law*. Los Angeles, University of California Press, 1967.
- Kelsen, H. (1965) “Professor Stone and the Pure Theory of Law”. En *Stanford Law Review*, Vol. 17, No 6.
- Nino, C. (1998) “Some Confusions surrounding Kelsen’s Concept of Validity”. En *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes* (Stanley Paulson, Bonnie Paulson Ed.). Oxford University Press, Oxford.
- Paulson S. y Paulson. B Editores (1998) *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*. Oxford, Oxford University Press.
- Raz, J. (1998) “Kelsen’s Theory of the Basic Norm”. En *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes* (Stanley Paulson, Bonnie Paulson Ed.). Oxford University Press, Oxford.
- Ross, A. (1969) *El concepto de validez y otros ensayos*. Mexico D.F., Distribuciones Fontamara, 2006.
- Troper, M. (2004) *Ensayos de teoría constitucional*. Mexico D.F., Distribuciones Fontamara.
- Tuori, K. (1998) *Positismo critico y derecho moderno*. Mexico D.F., Distribuciones Fontamara, 2004.